

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาราช

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2
ธันวาคม 2555

✧ บทความทั่วไป

- ความสับสนของการใช้คำในกฎหมาย : “ไม่สมบูรณ์” “ไม่บริบูรณ์”
- มารู้จักกับ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กันเถอะ
- การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศ
- กระบวนการตามกฎหมายสิทธิบัตรในการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐ :
การพัฒนากฎหมายของประเทศไทย
- กฎหมายป้องกันฟิชซิง : เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศไทย
- กฎหมายการแข่งขันกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

✧ แนะนำกฎหมายใหม่

✧ คำพิพากษากฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชา

✧ วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา

วิเคราะห์ข้อสอบ
ชุดวิชา



กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา

อาจารย์ อิงคริต คสเจิม

คำถาม

นายสมพงษ์เป็นหนี้เงินกู้นางสมศรี อยู่ 20,000 บาท นางสมศรีทวงถามให้ชำระหนี้หลายครั้งแล้ว แต่นายสมพงษ์ก็ยังไม่ยอมชำระให้ นางสมศรีได้ชู้นายสมพงษ์ว่า ถ้าไม่ยอมชำระหนี้แต่โดยดีจะนำเรื่องนี้ขึ้นฟ้องร้องต่อศาลและจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของนายสมพงษ์ทราบว่าเป็นหนี้เงินอยู่ 20,000 บาท ด้วย นายสมพงษ์กลัวมากจึงได้บอกนางสมศรีว่าจะนำเงินมาชำระให้ภายใน 3 วัน นางสมศรีเห็นว่าได้โอกาสจึงขอให้นายสมพงษ์ขายแจกันหยกโบราณให้แก่ตนด้วยในราคาเพียง 5,000 บาท ซึ่งความจริงแล้วราคากลางของแจกันหยกอยู่ในระหว่าง 10,000-12,000 บาท นายสมพงษ์ตกลงขายให้แต่โดยดี โดยจะนำแจกันมามอบให้ในวันรุ่งขึ้น ต่อมาในวันนั้นเอง นายสมพงษ์ได้ไปปรึกษานายณเดชน์ นายณเดชน์จึงแนะนำว่านายสมพงษ์ไม่ต้องชำระหนี้และไม่ต้องส่งมอบแจกันหยกตามสัญญา ดังนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่าคำแนะนำของนายณเดชน์ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

หลักกฎหมาย

มาตรา 164 การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆียะ

การข่มขู่ที่จะทำให้การใดตกเป็นโมฆียะนั้น จะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ข่มขู่มีผลต้องกลัว ซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้น การนั้นก็คงจะมีได้กระทำขึ้น

มาตรา 165 การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่

การใดที่กระทำไปเพราะนับถือว่าการนั้นได้กระทำเพราะถูกข่มขู่

วินิจฉัย

กรณีตามปัญหานี้ ประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาคือ การกระทำของนางสมศรีเป็นการข่มขู่อันจะทำให้นิติกรรมเป็นโมฆียะหรือไม่

ตามอุทาหรณ์ การขู่ว่าจะฟ้องคดีก็ดี การขู่ว่าจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าเป็นหนี้ก็ดีถือว่าการใช้สิทธิตามปกตินิยม ซึ่งบุคคลย่อมกระทำได้ตามกฎหมาย ไม่ถือว่าการข่มขู่แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการกระทำของนางสมศรีจึงไม่ตกเป็นโมฆียะสัญญาซื้อขายแจกันหยกอันมีผลเกิดจากการที่นางสมศรีขู่ว่าจะฟ้องคดีและจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชานายสมพงษ์ทราบหากนายสมพงษ์ไม่ชำระหนี้จึงสมบูรณ์ นายสมพงษ์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ด้วยการส่งมอบแจกันหยกให้แก่ตนนางสมศรี และนางสมศรีมีหน้าที่ที่จะต้องชำระราคาแก่นายสมพงษ์

สำหรับหนี้เงินกู้ซึ่งเป็นหนี้ชอบด้วยกฎหมาย นายสมพงษ์ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ตามกฎหมายอยู่แล้ว ไม่มีเหตุที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ได้ ไม่ว่าสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างนายสมพงษ์กับนางสมศรีจะเป็นโมฆียะเพราะเหตุช่มชู้หรือไม่ เพราะเป็นคณละครณีกันค้ำแะนนำของนายณเดชน์ไม่ถูกต้องตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

วิเคราะห์

จากคำถามในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ถือเป็นการช่มชู้ ตามป.พ.พ. มาตรา 165 ที่บัญญัติว่า ในกรณีการชู้ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่ถือว่าเป็นการช่มชู้ ซึ่งการชู้จะใช้สิทธิตามปกตินิยม คือ การใช้สิทธิที่มีอยู่ช่มชู้และเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หากไม่มีสิทธินั้นอยู่ในขณะช่มชู้ ไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิตามปกตินิยม เช่น การที่เจ้าหนี้ชู้ลูกหนี้ว่า หากไม่ชำระหนี้จะฟ้องร้องต่อศาล หรือชู้ว่าจะดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ ถ้าไม่ทำสัญญารับสภาพหนี้ให้ผู้ชู้ โดยมีหลักฐานว่าผู้ชู้มีมูลที่จะฟ้องคดีอาญาแก่ผู้ถูกชู้ฐานลักทรัพย์ เช่นนี้ถือเป็นการชู้โดยใช้สิทธิตามปกตินิยม

จากโจทย์การที่นางสมศรีชู้นายสมพงษ์ว่าจะฟ้องคดีกิดิ การชู้ว่าจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าเป็นหนี้กิดิถือว่าเป็นการใช้สิทธิตามปกตินิยมตามป.พ.พ. มาตรา 165 ซึ่งบุคคลย่อมกระทำได้ตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นการช่มชู้แต่อย่างใด เพราะฉะนั้นการกระทำของนางสมศรีจึงไม่ตกเป็นโมฆียะ เมื่อเป็นเช่นนั้นสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนอันมีผลเกิดจากการที่นางสมศรีชู้ว่าจะฟ้องคดีและจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชานายสมพงษ์ทราบหากนายสมพงษ์ไม่ชำระหนี้จึงสมบูรณ์ นายสมพงษ์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ด้วยการส่งมอบแลกเปลี่ยนให้แก่นางนางสมศรี และนางสมศรีมีหน้าที่ที่จะต้องชำระราคาแก่นายสมพงษ์นอกจากนี้หนี้เงินกู้ซึ่งเป็นหนี้ชอบด้วยกฎหมาย นายสมพงษ์ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ตามกฎหมายอยู่แล้ว ไม่มีเหตุที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ได้ ไม่ว่าสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างนายสมพงษ์กับนางสมศรีจะเป็นโมฆียะเพราะเหตุช่มชู้หรือไม่ เพราะเป็นคณละครณีกัน

อนึ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่วินิจฉัยในข้อนี้ผิดพลาดโดยวินิจฉัยว่าเมื่อนางสมศรีแสดงเจตนาโดยการช่มชู้แล้วย่อมเป็นโมฆียะทุกกรณีทั้งกรณีสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนและกรณีหนี้เงินกู้ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิดโดยในที่นี้เห็นได้ว่านักศึกษาศึกษาเฉพาะหลักกฎหมายในป.พ.พ. มาตรา 164 ที่วางหลักไว้ว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกช่มชู้เป็นโมฆียะแต่ไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ถือเป็นการช่มชู้ ตามป.พ.พ. มาตรา 165 ดังนั้น ในการศึกษาในลำดับต่อไปนักศึกษาควรจะต้องพิจารณาบริบทของหลักกฎหมายตลอดจนตรวจสอบว่าในหลักกฎหมายเรื่องนั้นมีข้อยกเว้นหรือไม่ หากมีข้อยกเว้นควรศึกษาว่ากฎหมายในเรื่องนั้นมีหลักการอย่างไรบ้างจึงจะทำให้นักศึกษาทำความเข้าใจมาตรานั้น เรื่องนั้น ได้อย่างถูกต้อง



กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ชัดเงางาม

คำถาม

นายสมชายเป็นเจ้าของสระว่ายน้ำ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาใช้บริการโดยเสียค่าบริการ เพื่อความประหยัดนายสมชายจึงไม่จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสระน้ำ และไม่จัดอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้ และได้ติดป้ายให้ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง ทางสระว่ายน้ำจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียชีวิตใด ๆ นางสาวสมศรี พาเด็กชายสมศักดิ์บุตรของตนอายุ 10 ปี มาว่ายน้ำ ขณะที่นางสมศรีเข้าห้องน้ำ เด็กชายสมศักดิ์จมน้ำ ขาดใจตาย กรณีเช่นนี้ ใครจะต้องรับผิดชอบทางละเมิดต่อการตายของเด็กชายสมศักดิ์

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

อธิบาย

มาตรฐานของความปลอดภัยในการจัดตั้งสระว่ายน้ำ จะต้องมีการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตจำเป็นเจ้าของสระว่ายน้ำเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปโดยเก็บค่าบริการจากผู้มาใช้บริการก็ต้องยึดถือตามมาตรฐานด้วย ยิ่งถ้าหากก่อนหน้านี้ก็มีผู้มาใช้บริการจมน้ำในสระว่ายน้ำมาแล้วเจ้าของสระว่ายน้ำยิ่งควรต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น แต่หากมิได้ปรับปรุงแก้ไข ถือว่าละเว้นปฏิบัติในสิ่งซึ่งตามวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสระว่ายน้ำควรต้องปฏิบัติ แม้เจ้าของสระว่ายน้ำจะปิดประกาศไว้ที่สระว่ายน้ำว่าผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ ผู้ปกครองของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำจะต้องมีผู้ดูแลรับผิดชอบด้วยตนเอง ก็ไม่ทำให้เจ้าของสระว่ายน้ำพ้นจากความรับผิดชอบ

สรุป นายสมชายต้องรับผิดชอบฐานละเมิดต่อการตายของเด็กชายสมศักดิ์ (โดยนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7292/43)

หมายเหตุ นักศึกษาจำนวนมากตอบว่านางสมศรีมารดาต้องร่วมรับผิดชอบในฐานละเมิดด้วย จึงต้อง
มาพิจารณาการกระทำของนางสมศรีด้วยการที่นางสมศรีเข้าห้องน้ำเพื่อทำกิจธุระส่วนตัวนั้นจะถือเป็นการจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ ซึ่งจากข้อเท็จจริงตามโจทย์ การที่นางสมศรีเข้าห้องน้ำนั้นยังไม่ถือว่าเป็นการจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อ อันอาจเป็นการละเมิดได้ การที่ศาลฎีกาตัดสินให้เจ้าของสระว่ายน้ำต้องรับผิดชอบละเมิดนี้
เป็นเพราะ ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของสระว่ายน้ำด้วยที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวิตไว้ด้วย ดังนั้น หากมีเหตุเกิดขึ้นกรณีมีเด็กจมน้ำเจ้าของสระว่ายน้ำจึงต้องรับผิดชอบดังกล่าว



กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก

รองศาสตราจารย์ วรุณี เทพทอง¹

คำถาม

นายตะวันอายุ 22 ปี หมั้นกับนางสาวอรุณอายุ 32 ปี ด้วยสร้อยทองหนัก 5 บาทเป็นของหมั้น โดยบิดามารดาของนายตะวันไม่เห็นชอบด้วย เพราะเห็นว่านางสาวอรุณมีอายุมากกว่านายตะวันมาก ทั้งคู่ตกลงจะสมรสกัน หลังจากนายตะวันเรียนจบปริญญาโทแล้ว ก่อนถึงกำหนดดังกล่าวบิดามารดาของนายตะวันจ้างนางสาวอรุณด้วยเงินสด 2 ล้านบาท เพื่อไม่ให้นางสาวอรุณสมรสกับนายตะวัน นางสาวอรุณเห็นว่าความรักของตนถูกกีดกันจึงหลบหนีไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยนายตะวันไม่ทราบข่าวของนางสาวอรุณเลย หลังจากนั้น 5 ปี เมื่อนางสาวอรุณกลับมาประเทศไทย ทราบข่าวว่านายตะวันจดทะเบียนสมรสกับนางสาวเย็นจิตร์แล้ว

ให้วินิจฉัยว่า นายตะวันผิดสัญญาหมั้นกับนางสาวอรุณหรือไม่ และนายตะวันมีสิทธิเรียกสร้อยทองดังกล่าวคืนจากนางสาวอรุณได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ ยกหลักกฎหมายตามป.พ.พ.มาตรา 1437 และมาตรา 1439

วินิจฉัย ตามปัญหานายตะวันอายุ 22 ปี หมั้นกับนางสาวอรุณอายุ 32 ปี ด้วยสร้อยทองหนัก 5 บาท เป็นของหมั้น แม้บิดามารดาของนายตะวันไม่เห็นชอบด้วย การหมั้นก็มีผลสมบูรณ์ ตามป.พ.พ.มาตรา 1437 ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อนายตะวันเรียนจบปริญญาโทแล้ว ก่อนถึงกำหนดดังกล่าว บิดามารดาของนายตะวันจ้างนางสาวอรุณด้วยเงินสด 2 ล้านบาท เพื่อไม่ให้นางสาวอรุณสมรสกับนายตะวัน นางสาวอรุณเห็นว่าความรักของตนถูกกีดกันจึงหลบหนีไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ย่อมเป็นกรณีที่นางสาวอรุณหญิงคู่หมั้นปฏิเสธการสมรสกับนายตะวันโดยไม่มีเหตุสำคัญที่จะอ้างได้ เป็นการผิดสัญญาหมั้น ตามป.พ.พ.มาตรา 1439 นางสาวอรุณต้องคืนสร้อยทองหนัก 5 บาท ที่เป็นของหมั้นให้แก่นายตะวันชายคู่หมั้น เมื่อนายตะวันไม่ทราบข่าวของนางสาวอรุณเลย และได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาวเย็นจิตร์แล้ว เช่นนี้จะถือว่านายตะวันเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นย่อมไม่ได้

สรุป นายตะวันไม่ผิดสัญญาหมั้นกับนางสาวอรุณ และนายตะวันมีสิทธิเรียกสร้อยทองดังกล่าวคืนจากนางสาวอรุณได้

¹ ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก

วิเคราะห์ คำถามข้อนี้ ต้องการให้นักศึกษาวินิจฉัยเรื่องการหมั้น ในประเด็นความสมบูรณ์ของสัญญาหมั้น การผิดสัญญาหมั้น และการเรียกของหมั้นคืน

1. ประเด็นความสมบูรณ์ของสัญญาหมั้น นักศึกษาต้องทราบถึงเงื่อนไขการหมั้นว่า ชายหญิงจะหมั้นกันได้อายุนั้นต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์แล้วทั้งคู่ มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 1435 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และถ้าคู่หมั้นเป็นผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลตามมาตรา 1436 ก่อน มิฉะนั้นเป็นโมฆะ ถ้าชายหญิงคู่หมั้นบรรลุนิติภาวะและอายุครบหรือเกิน 17 ปี แล้ว ย่อมหมั้นกันได้โดยลำพัง แม้อบิดามารดาจะไม่ยินยอมก็ตาม และเมื่อฝ่ายชายส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงคู่หมั้นแล้ว การหมั้นย่อมสมบูรณ์ ข้อเท็จจริงในคำถามปรากฏว่า นายตะวันอายุ 22 ปี หมั้นกับนางสาวอรุณอายุ 32 ปี ด้วยสร้อยทองหนัก 5 บาทเป็นของหมั้นด้วยแล้ว เช่นนี้ การหมั้นระหว่างนายตะวันกับนางสาวอรุณย่อมสมบูรณ์ตามมาตรา 1437 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2. ประเด็นการผิดสัญญาหมั้น การผิดสัญญาหมั้นนั้น เป็นการที่คู่หมั้นฝ่ายหนึ่งปฏิบัติการสมรสกับคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่คู่หมั้นที่ถูกปฏิเสธนั้นไม่มีเหตุสำคัญที่ไม่สมควรสมรสด้วย ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1439 บัญญัติไว้ และไม่ว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงคู่หมั้นผิดสัญญาหมั้น ย่อมบังคับตามบทบัญญัติดังกล่าว ข้อเท็จจริงตามคำถามมีว่าบิดามารดาของนายตะวันจ้างนางสาวอรุณด้วยเงินสด 2 ล้านบาทเพื่อไม่ให้นางสาวอรุณสมรสกับนายตะวัน นางสาวอรุณเห็นว่าความรักของตนถูกกีดกันจึงหลบหนีไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น เช่นนี้ เป็นกรณีที่นางสาวอรุณคู่หมั้นปฏิเสธการสมรสกับนายตะวันชายคู่หมั้นโดยนายตะวันไม่มีเหตุสำคัญถึงขนาดที่นางสาวอรุณไม่สมควรสมรสด้วย การที่บิดามารดากีดกันนางสาวอรุณไม่ให้สมรสกันก็ดี หรือการที่นายตะวันจดทะเบียนสมรสกับนางสาวเย็นจิตโดยที่นายตะวันไม่ทราบข่าวของนางสาวอรุณเลยเป็นเวลาถึง 5 ปี นั้นก็ดี ไม่เป็นเหตุที่นางสาวอรุณจะนำมาอ้างได้ว่าตนไม่ผิดสัญญาหมั้น เช่นนี้แล้ว นางสาวอรุณย่อมเป็นผู้ผิดสัญญาหมั้น ตามมาตรา 1439 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3. ประเด็นการเรียกของหมั้นคืน ในประเด็นนี้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 1439 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้น ให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย ดังนั้น ถ้านักศึกษาได้อ่านวินิจฉัยในประเด็นการผิดสัญญาหมั้นข้างต้นถูกต้องแล้ว ในประเด็นนี้ก็ย่อมวินิจฉัยถูกต้องไปด้วย หากนักศึกษาวินิจฉัยประเด็นการผิดสัญญาหมั้นผิดไปโดยวินิจฉัยว่า ฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้น ในประเด็นนี้ก็จะวินิจฉัยผิดตามไปด้วย

สำหรับคำถามข้อนี้ คะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่ประเด็นการผิดสัญญาหมั้นและการเรียกของหมั้นคืน ที่ส่วนประเด็นความสมบูรณ์ของสัญญาหมั้นเป็นคะแนนส่วนน้อย นักศึกษาส่วนใหญ่วินิจฉัยประเด็นความสมบูรณ์ของสัญญาหมั้นถูกต้อง และมีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่วินิจฉัยประเด็นการผิดสัญญาหมั้นและการเรียกของหมั้นคืนคลาดเคลื่อนอยู่มาก นักศึกษาบางคนนำความรู้สึกของตนเองเข้ามาวินิจฉัยด้วย เช่น เขียนตอบมาว่า นางสาวอรุณเป็นคนไม่หนักแน่น เห็นแก่เงิน บางคนถึงขนาดไปโทษว่านายตะวันเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นเพราะไม่ขัดขวางการกระทำของบิดามารดาตนเองบ้าง เป็นมีจิตใจไม่มั่นคงบ้าง ไม่รักจริงบ้างและบางคนเขียนต่อว่านางสาวอรุณและนายตะวันมาให้อาจารย์อ่านด้วย เหล่านี้ไม่เป็นประเด็นทางกฎหมาย นักศึกษาควรจับประเด็นในทางกฎหมาย

ให้ได้ว่า คำถามต้องการถามประเด็นใด และต้องใช้หลักกฎหมายมาปรับกับข้อเท็จจริง อย่าวินิจฉัยโดยอาศัยข้อเท็จจริงแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีหลักกฎหมายเลย และเมื่อนักศึกษาได้ยกหลักกฎหมายไว้แล้วในตอนต้น ซึ่งเป็นส่วนของหลักกฎหมาย ก็ต้องนำมาเขียนหรือยกมาปรับกับข้อเท็จจริงในส่วนวินิจฉัยตามปัญหาอีกแล้ว จึงเป็นส่วนสรุปต่อไป สำหรับนักศึกษาที่ตอบข้อนี้ไม่ถูกหรือสอบไม่ผ่านชุดวิชานี้ นั้น อาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ศึกษาทำความเข้าใจต่อไป เนื่องจากเรื่องผิดสัญญาหมั้นและเรื่องบอกเลิกสัญญาหมั้น เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาต้องศึกษาจนสามารถแยกความแตกต่างได้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีความเกี่ยวพันไปถึงการเรียกของหมั้นคืน และการเรียกค่าทดแทนอีกด้วย



กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ หอนพรัตน์

คำถาม

สมิงมีเรื่องทะเลาะวิวาทโกรธเคืองกับพะอูลุงของตนอย่างรุนแรงถึงขนาดเอาปืนไปดักยิงพะอูลุง แต่ปรากฏว่าสมิงเห็นบิดาของตนเดินมาในเวลากลางคืนมองแต่ไกลเข้าใจไขว้เขวว่าเป็นพะอูลุงเพราะรูปร่างใกล้เคียงกันจึงยิงไป 2-3 นัด ถูกบิดาของตนถึงแก่ความตาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับสมิงในข้อหาฆ่าบุพการีโดยเจตนา (ซึ่งเป็นโทษที่หนักกว่าการฆ่าคนตายธรรมดา) สมิงต่อสู้ว่าตนมิได้มีเจตนาฆ่าบิดาของตนแต่อย่างไร เป็นเพราะความไม่รอบคอบไม่ดูให้ดีเสียก่อนเท่านั้น

ให้ท่านวินิจฉัยว่าสมิงต้องรับผิดตามข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

มาตรา 61 บัญญัติว่า “ผู้ใดเจตนาจะกระทำต่อบุคคลหนึ่ง แต่ได้กระทำต่อบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิด ผู้นั้นจะยกเอาความสำคัญผิดเป็นข้อแก้ตัวว่ามีได้กระทำโดยเจตนาหาได้ไม่”

มาตรา 62 วรรคท้าย บัญญัติว่า “บุคคลจะต้องรับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงใด บุคคลนั้นจะต้องรู้ข้อเท็จจริงนั้น”

วินิจฉัย

สมิงมีเจตนาจะฆ่าพะอูลุง จึงเอาปืนไปดักยิงพะอูลุง แต่กลับไปยิงบิดาของตนเองเพราะเห็นบิดาตนเดินมาสำคัญผิดว่าเป็นพะอูลุงของตน จนบิดาถึงแก่ความตาย แม้สมิงจะมีเจตนาฆ่าพะอูลุง แต่กลับไปฆ่าบิดาของตน เพราะสำคัญผิดยิงผิดคนนั้น กฎหมายมิให้ผู้กระทำความผิดยกเอาความสำคัญผิดนั้นมาอ้างว่าตนมิได้มีเจตนา สมิงจึงต้องรับผิดทางอาญฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา (แม้จะฆ่าผิดคนก็ตาม) เจตนาที่มีต่อเป้าหมายแรกโอนมาที่ผู้ได้รับผลร้ายทั้งหมด

อนึ่ง แม้สมิงจะยิงบิดาของตนตาย ต้องรับผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา ก็รับผิดฐานฆ่าคนธรรมดาตายเท่านั้น ไม่ต้องรับโทษหนักขึ้นฐานฆ่าบุพการีตายแต่อย่างใด เพราะตอนที่ลั่นกระสุนปืนไปนั้น สมิงไม่รู้ว่าเป็นบิดาของตนกำลังยังเป็นบิดาของตน ซึ่งกฎหมายมาตรา 62 วรรคท้าย วางหลักว่าบุคคลต้องรับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงใด บุคคลนั้นต้องรู้ข้อเท็จจริงนั้น

สรุป

สมิงต้องรับผิดชอบฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา (โดยสำคัญผิด) แต่ไม่ต้องรับโทษหนักขึ้นฐานฆ่าบุพการีตายแต่อย่างใด

วิเคราะห์

1. นักศึกษาบางคนตอบในเรื่องเจตนาโดยพลาดมาตรา 60 เจตนาโดยพลาดและเจตนาโดยสำคัญผิด เหมือนกันคือผู้กระทำไม่ได้เจตนากระทำต่อผู้ได้รับผลร้าย แต่กฎหมายบัญญัติให้ผู้กระทำต้องรับผิดชอบกระทำโดยเจตนาต่อผู้รับผลร้ายคือถือว่ามีเจตนาซึ่งทางกฎหมายเรียกว่าเจตนาโดยผลของกฎหมาย เจตนาโดยพลาด และเจตนาโดยสำคัญผิด ต่างกันคือ

เจตนาโดยพลาดมีผู้เสียหาย 2 คน คือ ผู้เสียหายที่ผู้กระทำมีเจตนากระทำต่อ และผู้เสียหายซึ่งได้รับผลจากการกระทำโดยพลาด

เจตนาโดยสำคัญผิด นั้น มีผู้เสียหายคนเดียวคือผู้ได้รับผลร้ายเนื่องจากสำคัญผิดคิดว่าเป็นบุคคลที่เจตนากระทำต่อ

ฉะนั้น กรณีตามอุทธรณ์มีผู้เสียหายคนเดียวคือ บิดาของนายสวิงเท่านั้น นายพะอู ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย จึงเป็นเรื่องเจตนาโดยสำคัญผิด มาตรา 61

2. นักศึกษามักจะไม่ตอบมาตรา 62 วรรคท้าย แต่จะไปตอบ มาตรา 60 ซึ่งจะเสียคะแนนในส่วนนี้ แต่ตรงคำตอบจะเหมือนกัน คือ รับผิดชอบฆ่าบุคคลธรรมดา เหตุผลที่ใช้มาตรา 62 วรรคท้าย เพราะมาตรา 61 เป็นเรื่องการสำคัญผิดในข้อเท็จจริง ซึ่งมีบทบัญญัติเฉพาะแล้วในมาตรา 62 จะไปใช้บทบัญญัติในมาตราอื่นไม่ได้



กฎหมายอาญา 2 : ภาควิชาความผิด

รองศาสตราจารย์ สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นายทองเกลียดนายเขียวที่ชอบมาเล่นซุกกับภรรยาของตน จึงคิดจะไปฆ่านายเขียว คืนหนึ่งนายทองได้แอบเดินไปยืนอยู่ใกล้บ้านของนายเขียว ในขณะที่นายทองกำลังลี้ลับว่าจะจุดไฟเผาบ้านของนายเขียวเพื่อให้ไฟครอกนายเขียวนายดี หรือจะขึ้นไปฆ่านายเขียวในห้องนอนดี นายทองรู้สึกเครียดจึงจุดบุหรี่สูบ เมื่อบุหรี่ใกล้จะหมดมวน นายทองจึงตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะขึ้นไปฆ่านายเขียวให้ตายดีกว่า แล้วนายทองก็โยนกำนันบุหรี่ที่เหลือทิ้งไป บังเอิญกำนันบุหรี่ได้ไปหล่นบนกอหญ้าแห้งข้างบ้านของนายเขียว ทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงจนเกือบจะเผาบ้านของนายเขียวและเกือบทำให้นายเขียวที่กำลังนอนหลับอยู่ในบ้านถึงแก่ความตาย พอดีชาวบ้านมาช่วยดับไฟไว้ได้ทัน ไฟจึงไม่ไหม้บ้านของนายเขียว และนายเขียวก็ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด ดังนี้ นายทองต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 225) บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท และเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย หรือการกระทำโดยประมาทนั้นน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่น ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายทองจุดบุหรี่สูบและโยนกำนันบุหรี่ที่เหลือทิ้งไปโดยไม่ดูว่ากำนันบุหรี่ยานั้นจะไปหล่นที่ใด ถือว่านายทองได้กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะพึงมีตามวินัยและพฤติการณ์ จึงถือได้ว่านายทองได้กระทำโดยประมาท และเมื่อกำนันบุหรี่ได้ไปหล่นบนกอหญ้าแห้งข้างบ้านนายเขียว จนทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงจนเกือบจะเผาบ้านของนายเขียวและตัวนายเขียวที่กำลังนอนหลับอยู่ในบ้าน พอดีชาวบ้านได้มาช่วยดับไฟไว้ได้ทัน ไฟจึงไม่ไหม้บ้านของนายเขียวและตัวนายเขียวก็ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด กรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าแม้การกระทำโดยประมาทของนายทองจะยังไม่เกิดผลคือความเสียหายในทรัพย์สินของผู้อื่น แต่ก็มีพฤติการณ์ประกอบความผิดคือน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่นคือตัวนายเขียว ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าเพียงมีพฤติการณ์เช่นนี้ก็มีความผิดแล้ว

ดังนั้น นายทองจึงต้องรับผิดฐานกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท ตามหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ไม่ยาก นักศึกษาอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีว่าต้องเป็นเรื่องวางเพลิงเผาทรัพย์แน่นอน แต่นักศึกษาไปสับสนในตอนต้น ที่บอกว่านายทองกำลังลั้งเลว่าจะจุดไฟเผาบ้านของนายเขียวเพื่อให้ไฟครอก นายเขียวดีหรือจะขึ้นไปฆ่านายเขียวในห้องนอนดี โดยสรุปว่านายทองได้คิดจะเผาบ้านของนายเขียวแล้ว จึงพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ ทั้ง ๆ ที่นายทองเพียงแต่คิดยังไม่ได้กระทำถึงขั้นลงมือเผาจึงยังไม่ใช่ความผิดฐานพยายาม แต่ในตอนหลังที่นายทองโยนกำธนูปที่เหลือทิ้งไป บังเอิญกำธนูปได้ไปหล่นบนกอหญ้าแห้งข้างบ้านของนายเขียว จะเห็นได้ว่านายทองไม่มีเจตนาจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือแม้แต่เจตนาจะโยนกำธนูปใส่ในกอหญ้าแห้งข้างบ้านนายเขียวเลย แต่การที่นายทองโยนกำธนูปซึ่งยังมีไฟติดอยู่ไปโดยไม่ดูให้ดีเสียก่อน ต้องถือว่านายทองกระทำโดยประมาทขาดความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะพึงมีตามวิสัยและพฤติการณ์และการกระทำโดยประมาทของนายทอง ทำให้เกือบจะเผาบ้านของนายเขียวและเกือบทำให้นายเขียวที่กำลังนอนหลับอยู่ในบ้านถึงแก่ความตาย ในประเด็นนี้นักศึกษาที่ว่าตัวบทกฎหมายไม่ได้ ก็มักจะตอบว่านายทองผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์อีก เพราะบ้านของนายเขียวก็ยังไม่ถูกเผาและตัวนายเขียวก็ยังไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด ซึ่งจริง ๆ แล้วในความผิดฐานกระทำโดยประมาทนี้จะไม่มีการกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท กฎหมายก็เขียนเพียงว่าเขียน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่นก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว จึงทำให้นักศึกษาเสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย

ในการสอบครั้งนี้ต่อไป ขอให้นักศึกษาอ่านตัวบทกฎหมายให้มากขึ้น อ่านคำอธิบายให้มากขึ้น ก็จะทำให้นักศึกษาสอบผ่านได้โดยง่าย ขอให้โชคดีคะ



กฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

รองศาสตราจารย์ วิมาน กฤตพลวิมาน

คำถาม

ทองตกลงด้วยวาจาขายบ้านพร้อมที่ดินแปลงหนึ่งให้แก่ นาก โดยนัดจะไปโอนทางทะเบียนพร้อมทั้งชำระราคาในคราวเดียวหลังปีใหม่ ก่อนการโอนทองยินยอมให้นากเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านพร้อมที่ดินนั้นได้ หลังปีใหม่ทองได้ตรวจสอบราคาแล้วรู้สึกว่าการขายให้แก่ นากนั้นถูกเกินไป จึงเปลี่ยนใจไม่ยอมจดทะเบียนโอนขาย โดยอ้างว่าสัญญาใช้บังคับกันไม่ได้ เพราะเป็นเพียงการตกลงด้วยวาจา และได้มีการวางมัดจำกันไว้ แต่ประการใด จึงแจ้งให้นากออกจากบ้านพร้อมที่ดินแปลงดังกล่าว เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า นากจะมีข้อต่อสู้ อย่างไร หรือไม่

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง สัญญาจะขายหรือจะซื้อ หรือค้ำประกันในการซื้อขายทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบหรือได้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้วจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

ตามปัญหา ทองตกลงด้วยวาจาขายบ้านพร้อมที่ดินแปลงหนึ่งให้แก่ นาก โดยนัดจะไปโอนทางทะเบียนพร้อมทั้งชำระราคาในคราวเดียวหลังปีใหม่ เมื่อมีข้อตกลงไปโอนทางทะเบียนกันในภายหลัง สัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าวจึงมิใช่สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด หากแต่เป็นสัญญาจะซื้อจะขายตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง แม้การซื้อขายดังกล่าวจะมีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคหนึ่ง แต่ประการใด การซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าว แม้จะเป็นเพียงการตกลงด้วยวาจา และได้มีการวางมัดจำกันไว้ แต่การที่ทองยินยอมให้นากเข้าไปอาศัยในบ้านพร้อมที่ดินนั้นได้ ย่อมถือได้ว่าได้มีการชำระหนี้บางส่วนแล้วสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวจึงฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง

ฉะนั้น นากจึงมีข้อต่อสู้ว่าได้มีการชำระหนี้บางส่วนแล้ว สัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวจึงฟ้องร้องบังคับคดีกันได้

วิเคราะห์ข้อสอบ

ประเด็นหลักในข้อนี้จะต้องตอบว่าสัญญาระหว่างทองกับนากเป็นสัญญาจะซื้อจะขายตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง มิใช่สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด เพราะเป็นกรณีจะนัดไปโอนทางทะเบียนภายหลังจากที่ตกลงซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าว และในการที่ทองยินยอมให้นากเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านพร้อมที่ดินนั้น ได้ถือเป็นการชำระหนี้บางส่วน ซึ่งมีผลทำให้สัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง

ข้อสอบข้อนี้นักศึกษาจำนวนมากใช้หลักกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคหนึ่ง แล้ววินิจฉัยว่าการซื้อขายระหว่างทองกับนากซึ่งเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แต่ตกลงกันด้วยวาจาทำให้มีผลเป็นโมฆะตาม มาตรา 456 วรรคหนึ่ง ซึ่งไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ใช้หลักกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 458 แล้วไปวินิจฉัยในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ที่บ้านพร้อมที่ดินได้มีการโอนไปตั้งแต่ขณะทำสัญญาซื้อขายกันแล้ว ซึ่งก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน

ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ยกหลักกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง แต่วินิจฉัยผิด โดยวินิจฉัยว่าการที่ทองตกลงด้วยวาจาขายบ้านพร้อมที่ดินให้นาก โดยยินยอมให้นากเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านพร้อมที่ดินนั้นยังไม่ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิด วางประจำ หรือชำระหนี้บางส่วน มีผลทำให้ไม่สามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสองได้แต่ประการใด

คำถาม

นายปุ่นชื่นชอบฝีมือทำอาหารของนางสา เนื่องจากเคยชิมอาหารที่นางสาทำ นายปุ่นจึงตกลงให้นางสาทำอาหารเย็นส่งให้นายปุ่น โดยนางสาจะต้องนำอาหารไปส่งที่บ้านนายปุ่นทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งนางสาจะทำอาหารประเภทใดก็ได้ นางสาเลือกที่จะทำอาหารที่บ้านของตนโดยมีครัวแยกออกมาต่างหากจากตัวบ้าน เช้าวันหนึ่งนางสาสั่งเครื่องปรุงและส่วนประกอบในการทำอาหารเก็บไว้ในห้องครัวเพื่อทำอาหารส่งให้แก่ นายปุ่น ในตอนเย็น แต่เผอิญวันนั้นช่วงกลางวันเป็นวันที่อากาศร้อนมาก ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ครัวของนางสาถูกไฟไหม้วอดวายหมด ทำให้นางสาไม่สามารถทำอาหารส่งให้นายปุ่นในวันดังกล่าว ให้ท่านวินิจฉัยว่านายปุ่นจำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างในการทำอาหารแก่นางสาหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

มาตรา 603 ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ และการที่จ้างทำ นั้นพังทลายหรือบุบสลายลงก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซ้ ท่านว่า ความวินาศอันนั้นตกเป็นพับแก่ผู้รับจ้าง หากความวินาศนั้นมิได้ เป็นเพราะการกระทำของผู้ว่าจ้าง

ในกรณีเช่นว่านี้ สิ้นจ้างก็เป็นอันไม่ต้องใช้

วินิจฉัย

การที่นายปูนตกลงให้นางสาทำอาหารเย็นส่งให้นายปูนที่บ้านทุกวันเป็นเวลา 1 เดือนนั้น เป็นการจ้างทำของ เพราะมุ่งที่ผลสำเร็จของงาน

จากข้อเท็จจริง นางสาเป็นผู้จัดหาสัมภาระในการที่จ้างเอง ซึ่งก็คือ เครื่องปรุงและส่วนประกอบในการทำอาหารไว้ที่ห้องครัวของตน เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้วอดวายหมดโดยไม่ได้เกิดจากการกระทำของนายปูนผู้ว่าจ้าง นางสาจึงเป็นผู้ที่ต้องรับผลในความวินาศนั้น

ดังนั้น นายปูนจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในการทำอาหารแก่นางสา

วิเคราะห์ข้อสอบ

ข้อสอบค่อนข้างง่าย โดยการวินิจฉัยก็จะเป็นไปตามหลักตาม ป.พ.พ. มาตรา 603 ที่หากว่านักศึกษา ยกหลักกฎหมายตามมาตรานี้ ซึ่งเป็นกรณีนางสาผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ เมื่อเหตุภัยพิบัติในความวินาศ ก็จะตกเป็นพับแก่ผู้รับจ้าง แต่จะต้องมีใช่เป็นความวินาศที่เกิดจากการกระทำของนายปูนผู้ว่าจ้าง และก็มีผลทำให้ นายปูนผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายสินจ้างหรือค่าจ้างในการทำอาหารแก่นางสา

นักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจข้อเท็จจริงแล้วใช้หลักกฎหมายปรับวินิจฉัยกับข้อเท็จจริงได้ถูกต้อง แต่ก็มีนักศึกษาจำนวนมากที่ไม่ยกหลักกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 603 แล้ววินิจฉัยไปตามเหตุผลของนักศึกษาเอง ทำให้ได้คะแนนไม่ดีขึ้น ไรก็ตาม ยังคงมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งไปพิจารณาและวินิจฉัยว่าสัญญาตามโจทย์ข้อนี้เป็นสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งถือว่าผิดพลาดตั้งแต่การอ้างหลักกฎหมายและการวินิจฉัย



กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ผากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย สอบไล่ภาค 1/2555

รองศาสตราจารย์ จิตรา เพียรล้ำเลิศ

คำถาม

นายเปรี๊ยะทำสัญญาประกันชีวิตของตนกับบริษัทเมืองนนประกันชีวิต มหาชนจำกัด วงเงิน 1 ล้านบาท ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 สัญญามีกำหนด 10 ปี โดยระบุให้นายหวานบุตรชายเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมาวันที่ 15 กันยายน 2555 นายหวานซึ่งติดการพนันอย่างหนัก ต้องการหาเงินมาใช้หนี้พนัน จึงวางแผนฆ่านายเปรี๊ยะเพื่อเอาเงินประกันชีวิต และอีกสองวันถัดมาขณะนายเปรี๊ยะหลับ นายหวานใช้ปืนยิงนายเปรี๊ยะหนึ่งนัดแล้วหลบหนีไป แต่ปรากฏว่ากระสุนปืนไม่ถูกอวัยวะสำคัญนายเปรี๊ยะจึงเพียงได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อนายเปรี๊ยะสืบทราบว่ายิงตนคือนายหวานบุตรชายของตนจึงเกิดน้อยใจอย่างมากและดื่มยาพิษฆ่าตัวตาย ภายหลังจากที่นายเปรี๊ยะตายนายหวานได้ไปขอรับเงินประกันชีวิตจำนวน 1 ล้านบาทจากบริษัทเมืองนนประกันชีวิต มหาชนจำกัด

ให้ท่านวินิจฉัยว่า บริษัทเมืองนนประกันชีวิต มหาชนจำกัด จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวน 1 ล้านบาทตามสัญญาประกันชีวิตแก่นายหวานหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ป.พ.พ. มาตรา 895 บัญญัติว่า “เมื่อใดจะต้องใช้จำนวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคนหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำต้องใช้เงินนั้นในเมื่อมรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่

- (1) บุคคลผู้นั้นได้กระทำอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันทำสัญญาหรือ
- (2) บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประกันภัยฆ่าตายโดยเจตนา

ในกรณีที่ 2 นี้ท่านว่า ผู้รับประกันภัยจำต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้นั้น”

ตามหลักกฎหมาย ป.พ.พ. มาตรา 895 ข้างต้น บัญญัติให้ผู้รับประกันชีวิตได้รับยกเว้นไม่จำต้องใช้เงินในเหตุมรณภัยของบุคคลตามสัญญาประกันชีวิต หากปรากฏว่า บุคคลผู้นั้นกระทำอัตวินิบาตคือฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันทำสัญญา หรือบุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประกันภัยฆ่าตายโดยเจตนา

กรณีตามปัญหา นายเปรี๊ยะทำสัญญาประกันชีวิตของตนเองวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยระบุให้ นายหวานบุตรชายเป็นผู้รับประโยชน์ ต่อมาวันที่ 15 กันยายน 2555 นายหวานผู้รับประโยชน์ต้องการฆ่า นายเปรี๊ยะผู้เอาประกันชีวิตเพื่อหวังเอาเงินตามสัญญาประกันชีวิตไปใช้หนี้พนันจึงได้ใช้ปืนยิงนายเปรี๊ยะ แต่ปรากฏว่านายเปรี๊ยะเพียงแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่ถึงแก่กรรมะ จึงมิใช่เป็นกรณีผู้เอาประกันชีวิตถูกผู้รับประโยชน์ ฆ่าตายโดยเจตนา และการที่นายเปรี๊ยะน้อยใจจึงดื่มยาพิษฆ่าตัวตายภายหลังจากนั้น แม้จะถือว่าเป็นกรณี ผู้เอาประกันชีวิตกระทำอัตวินิบาตด้วยใจสมัครก็ตาม แต่ก็เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา กรณีจึง ไม่เข้าข้อยกเว้นตามป.พ.พ. มาตรา 895 (2) (1) ซึ่งบริษัทเมืองนนประกันชีวิต มหาชนจำกัด จะยกเป็นข้ออ้าง เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบได้

ดังนั้น บริษัทเมืองนนประกันชีวิต มหาชนจำกัด จึงต้องรับผิดชอบจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิต จำนวน 1 ล้านบาทให้แก่ นายหวานผู้รับประโยชน์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

วิเคราะห์

สำหรับคำถามข้อนี้พบว่า มีนักศึกษาบางส่วนตอบคำถามโดยมีข้อผิดพลาดบางประการ คือ

1. กรณีตามปัญหา ต้องอ้างหลักกฎหมาย ป.พ.พ. มาตรา 895 ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่ผู้รับประกันภัย ไม่จำต้อง “ใช้เงินจำนวนตามกำหนด” ในเหตุมรณะตามสัญญาประกันชีวิต แต่นักศึกษากลับอ้างหลักกฎหมาย ว่าเป็นข้อยกเว้นไม่จำต้อง “ชดเชยค่าสินไหมทดแทน” อันแสดงถึงความไม่เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสัญญา ประกันชีวิตและสัญญาประกันวินาศภัยว่า สัญญาประกันชีวิตนั้นมิใช่สัญญาที่มุ่งชดเชยค่าสินไหมทดแทน (non- indemnity contract) เช่นสัญญาประกันวินาศภัย

2. นักศึกษาบางส่วนมิได้วินิจฉัยในประเด็นแรกว่า กรณีตามข้อเท็จจริงไม่เข้าข้อยกเว้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 895 (2) เนื่องจากผู้เอาประกันชีวิตมิได้ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย แต่นักศึกษากลับมุ่งวินิจฉัย ประเด็นผู้เอาประกันชีวิตกระทำอัตวินิบาตด้วยใจสมัคร เกินกว่า 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่เข้า ข้อยกเว้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 895 (1) เพียงประเด็นเดียวเท่านั้น

3. นักศึกษาจำนวนมากเข้าใจหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 895 (1) คลาดเคลื่อนไป โดย เข้าใจว่า เมื่อผู้เอาประกันชีวิตกระทำอัตวินิบาตด้วยใจสมัคร ผู้รับประกันภัยก็ได้รับยกเว้นความรับผิดชอบแล้ว ซึ่งอันที่จริงตาม ป.พ.พ. มาตรา 895 (1) ผู้เอาประกันชีวิตจะต้องกระทำอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาด้วย ผู้รับประกันภัยจึงจะได้รับยกเว้นความรับผิดชอบ

4. นักศึกษาจำนวนไม่น้อยวินิจฉัยประเด็นตาม ป.พ.พ. มาตรา 895 (2) ว่า เพียงแต่ผู้รับประโยชน์ มีเจตนาฆ่าผู้เอาประกันชีวิต ก็เข้าข้อยกเว้นความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยแล้ว โดยมีได้คำนึงว่า ผู้เอาประกันชีวิต- ได้มรณะเพราะเหตุที่ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าหรือไม่ ซึ่งไม่ถูกต้อง

5. นักศึกษาบางส่วนก็อ้างหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 895 (2) คลาดเคลื่อนไป โดยอ้างว่า ผู้รับประกันภัยได้รับยกเว้นความรับผิด หากผู้รับประกันภัยเป็น “ผู้ก่อให้เกิดเหตุมรณะ” ของผู้เอาประกันชีวิต ซึ่งไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 895 (2) นั้น ต้องปรากฏว่า ผู้เอาประกันชีวิตถูกผู้รับประกันภัย “ฆ่าตายโดยเจตนา” ด้วย มิใช่ผู้รับประกันภัยเพียงเป็นผู้ก่อให้เกิดเหตุมรณะ ซึ่งอาจมิได้เนื่องมาจากเจตนาฆ่า เช่น เพียงแต่ประมาทเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ซึ่งย่อมไม่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าว ดังนั้น นักศึกษาจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ของกฎหมายให้ถูกต้อง



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

อาจารย์ พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล

ข้อ 1

คดีแรก นายแดงฟ้องนายเขียวว่า นายเขียวบุกรุกครอบครองที่พิพาทของนายแดง ขอให้ขับไล่ นายเขียวออกไปจากที่พิพาท ต่อมานายเขียวเป็นโจทก์ฟ้องนายแดงเป็นจำเลยขอให้ขับไล่ นายแดงออกไปจากที่พิพาทของตน จำเลยทั้งสองคดีให้การต่อสู้ว่าที่พิพาทเป็นตน ปรากฏว่าการพิจารณคดีหลังเสร็จก่อนคดีแรก และศาลชั้นต้นในคดีหลังพิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของนายเขียว นายเขียวจึงยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นในคดีแรกว่า ฟ้องของนายแดงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำและเป็นฟ้องซ้ำกับคดีหลัง

ให้วินิจฉัยว่า คำแถลงของนายเขียวรับฟังได้หรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย ป.วิ.พ. มาตรา 144 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เมื่อศาลใดมีคำพิพากษา หรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้ว ห้ามมิให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้น เว้นแต่...”

มาตรา 148 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “คดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วห้ามมิให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีก ในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน เว้นแต่...”

วินิจฉัย

ตามคำฟ้องและคำให้การในคดีทั้งสองสำนวนมีประเด็นข้อพิพาทซึ่งศาลจะต้องวินิจฉัยอย่างเดียวกันว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือจำเลย และเป็นคู่ความเดียวกัน เมื่อศาลชั้นต้นในคดีหลังพิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของนายเขียว ฟ้องของนายแดงในคดีแรกจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตาม ป.วิ.พ. มาตรา 144 วรรคหนึ่ง แต่ไม่เป็นการฟ้องซ้ำเพราะขณะที่นายแดงยื่นฟ้อง ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดในประเด็นที่นายแดงเป็นโจทก์นำมาฟ้อง

ดังนั้น คำแถลงที่ว่าฟ้องของนายแดงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำกับคดีหลัง รับฟังได้ ส่วนคำแถลงที่ว่าฟ้องของนายแดงเป็นฟ้องซ้ำกับคดีหลัง รับฟังไม่ได้

วิเคราะห์

คำถามในข้อนี้มีสองประเด็นที่จะต้องนำมาวินิจฉัย ดังนี้

- กรณีคำแถลงว่าเป็นกรณีดำเนินการสอบสวนพิจารณาคดีซ้ำ และ
- กรณีคำแถลงว่าฟ้องของนายแดงเป็นฟ้องซ้ำ

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำเข้าอย่างกระจ่างทั้งสองประเด็น ที่จะทำให้นักศึกษาสามารถตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้อง

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด สำหรับข้อสอบข้อนี้คือ นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น และด้วยเหตุที่ตอบเพียงประเด็นเดียวนี้เอง ทำให้คะแนนที่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควรจะได้
2. นักศึกษาส่วนใหญ่จำหลักกฎหมายสับสนระหว่างการดำเนินการสอบสวนการพิจารณาคดีซ้ำ และการฟ้องซ้ำ ทำให้การเขียนอธิบายเกิดความสับสน มีนงง ผู้ตรวจเลยไม่แน่ใจว่านักศึกษากำลังอธิบายการดำเนินการสอบสวนการพิจารณาคดีซ้ำหรือเป็นการฟ้องซ้ำแน่
3. ข้อผิดพลาดประการสุดท้าย คือ นักศึกษาจำหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีซ้ำและการฟ้องซ้ำได้ แต่นักศึกษาเขียนอธิบายแต่หลักเกณฑ์ รวมถึงบางท่านได้มีการแยกแยะความแตกต่างในประเด็นทั้งสองอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก แสดงถึงความเข้าใจแบบกระจ่าง ชัดเจนของนักศึกษา แต่นักศึกษาส่วนใหญ่เมื่ออธิบายหลักเกณฑ์ความแตกต่างแล้วกลับลืมที่จะเขียนตัวบทกฎหมาย ทำให้คะแนนในส่วนของตัวบทได้น้อยลงไป จากที่ควรจะได้ คะแนนเต็ม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆ

ข้อ 2

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาซื้อที่ดินมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) จากโจทก์ ในราคา 100,000 บาท โดยทำสัญญากันเป็นหนังสือแต่ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โจทก์ส่งมอบการครอบครองที่ดินให้จำเลยแล้ว แต่จำเลยไม่ชำระราคาให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 100,000 บาท แก่โจทก์ จำเลยให้การต่อสู้ว่าชำระราคาให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้วขอให้ยกฟ้อง หากข้อเท็จจริงได้ความว่า สัญญาซื้อขายมีข้อความว่าผู้ซื้อชำระราคาให้ผู้ขายครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญา ให้วินิจฉัยว่า โจทก์จะนำพยานบุคคลมาสืบว่าจำเลยยังไม่ชำระราคาแก่โจทก์ได้หรือไม่

แนวตอบ

ป.วิ.พ. มาตรา 94 วรรค 1 บัญญัติว่า “เมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ แม้ถึงว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้ยินยอมก็ดี

(ก) ...

(ข) ขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อนำเอกสารมาแสดงแล้วว่า ยังมีข้อความ...หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีก”

วินิจฉัย

จำเลยซื้อที่ดิน ซึ่งมี น.ส.3 ก โดยมีได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ย่อมตกเป็นโมฆะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคหนึ่ง แต่ย่อมเป็นอันสมบูรณ์โดยฐานนิติกรรมอย่างอื่นได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 174 กรณีปรากฏว่าโจทก์ได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินให้จำเลยแล้วซึ่งกระทำได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1378 ตาม พฤติการณ์สันนิษฐานได้ว่าคู่กรณีตั้งใจให้สมบูรณ์เป็นสัญญาโอนการครอบครองโดยมีค่าตอบแทนซึ่งไม่มี กฎหมายบังคับว่าต้องมีเอกสารมาแสดง โจทก์นำพยานบุคคลมาสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารว่า จำเลยยังไม่ชำระราคาได้ ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 94 วรรค 1

วิเคราะห์

การตอบข้อสอบในข้อนี้ จะต้องมีความเข้าใจในหลักกฎหมายทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั้งยังต้องมีความเข้าใจในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วย ข้อสอบข้อนี้ถือว่าเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก และ นักศึกษาส่วนใหญ่เกิดความสับสน นักศึกษาต้องเข้าใจว่า แม้การซื้อขายที่ดินโดยมิได้จดทะเบียน จะตกเป็นโมฆะ แต่ย่อมสมบูรณ์โดยฐานนิติกรรมอย่างอื่นได้ ซึ่งหากพิจารณาจากโจทก์แล้ว มีการส่งมอบการครอบครองที่ดิน ให้แก่จำเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นถือว่า คู่กรณีตั้งใจให้สมบูรณ์เป็นสัญญาโอนการครอบครองโดยมี ค่าตอบแทนซึ่งไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องมีเอกสารมาแสดง เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องด้วย ป.วิ.พ. มาตรา มาตรา 94 วรรค 1 ดังนั้น โจทก์จึงสามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด สำหรับข้อสอบข้อนี้คือ นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบหลักกฎหมาย ผิดมาตรา บ้างก็อ้างผิดเรื่อง บ้างก็อ้างมาตรา 84 บ้างก็อ้างมาตรา 84/1 หรือไม่ก็อ้างมาตรา 94 วรรค 2 ซึ่งเป็นการอ้างที่เกิดจากความเข้าใจผิด แสดงให้เห็นว่า นักศึกษายังมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างไม่ชัดเจน เท่าที่ควร นักศึกษาบางท่านเมื่ออ่านโจทก์เสร็จถึงขนาดถอดใจไม่เขียนอะไรมาเลยก็มี แต่อย่างไรก็ดี ข้อสอบข้อนี้ ถือว่าเป็นข้อสอบที่ยากพอสมควร อาจารย์ผู้ตรวจก็ทราบดีถึงความยาก จึงมิได้ใจร้ายใจดำกับนักศึกษามากนัก แต่ถ้าตอบมาผิดตรงหรือผิดมาตราเลย ก็ยากที่อาจารย์จะแสวงหาคะแนนมาให้นักศึกษาได้

2. ข้อผิดพลาดประการที่สองคือ นักศึกษาส่วนใหญ่มิได้มีการอ้างถึงมาตรา 456 วรรคหนึ่งและ มาตรา 174 เลย สำหรับประเด็นนี้ แม้ว่านักศึกษาจะจำเลขมาตราไม่ได้ แต่หากเข้าใจและเขียนอธิบายมา ก็เป็นที่แน่นอนว่านักศึกษาท่านนั้นย่อมได้คะแนนในส่วนนี้ไปอย่างปราศจากข้อสงสัย (ซึ่งได้คะแนนดีด้วย) แต่นักศึกษา ส่วนใหญ่ยังสับสน และเข้าใจผิดประเด็นจึงไม่ได้มีการอ้างหลักกฎหมายในเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสนับสนุนคำตอบ ของตน

3. ข้อผิดพลาดประการสุดท้ายคือการที่นักศึกษาไม่ได้อ่านหนังสือมาสอบมาสอบ ทำให้ต้องแต่งนิยายขึ้นมาเพื่อสนับสนุนความเข้าใจของตนเอง รวมถึงการสร้างหลักกฎหมายใหม่ๆซึ่งบัญญัติโดยตนเองนั้น แน่ชอน ย่อมไม่ได้คะแนนจากผู้ตรวจ เนื่องจากไม่มีหลักใดๆตามตัวบทกฎหมายเลย มีแต่หลักความน่าจะเป็น น่าจะถูกต้อง ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาท่านใดที่แต่งกฎหมายขึ้นมาเอง ก็น่าจะสอบไม่ผ่านอย่างแนชอน



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

อาจารย์ ธนวัฒน์ เนติโพธิ์

คำถาม

- ก. การขาดนัดพิจารณามีหลักเกณฑ์อย่างไร
- ข. ศาลชั้นต้นชี้สองสถานแล้วกำหนดให้โจทก์นำสืบก่อน ในวันสืบพยานคู่ความมาศาล สืบพยานโจทก์ได้ 1 ปากแล้วเลื่อนคดีไป ในวันนัดที่สอง โจทก์มาศาลแต่จำเลยไม่มาศาล สืบพยานโจทก์อีก 1 ปาก โจทก์ส่งเอกสารเป็นพยาน 1 ฉบับ แล้วโจทก์ขอนัดวันสืบพยานโจทก์ต่อไป ศาลอนุญาต ดังนี้ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาหรือเสียสิทธิในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างไรหรือไม่

ข้อวิจารณ์

ข้อสอบข้อนี้มีแนวคำถามคล้ายกับที่เคยออกสอบไปแล้วเมื่อการสอบไล่สอบซ่อม 2/2554 คือ มีคำถามย่อย 2 ข้อ ซึ่งนักศึกษาอาจคิดว่ายาก เนื่องจากมีคำถามถึง 2 ข้อ โดยเฉพาะข้อ ข. ที่ถามว่ากรณีตามอุทหาหรณ์จะถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาหรือเสียสิทธิในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างไร

ในคำถามข้อแรกนั้น เป็นเรื่องที่ต้องการให้นักศึกษาอธิบายหลักเกณฑ์ของการขาดนัดพิจารณาเสียก่อน เมื่ออธิบายมาก็จะได้คะแนนในส่วนนี้ทันที แม้จะตอบตรงคำตอบในข้อ 2 ผิดก็ตาม ที่ข้อสอบช่วงหลังจะเป็นแนวนี้ เพราะจากการสอบหลายครั้งที่ผ่านมานักศึกษามักจะตอบแต่ตรงคำตอบโดยไม่อธิบายหลักกฎหมายเสียก่อนทำให้ไม่ได้คะแนนอย่างที่ควรเป็น (ที่ถูกต้องแล้วนักศึกษาจะต้องอธิบายหลักกฎหมายในเรื่องที่ถามเสียก่อนแล้วจึงค่อยปรับข้อเท็จจริงตามข้อสอบเข้ากับหลักกฎหมาย)

ในข้อ ข. ส่วนแรกที่ถามว่า จะถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาหรือไม่ นักศึกษาคงตอบได้ไม่ยาก เพราะเป็นการถาม-ตอบตามตัวบทตรง ๆ และได้กล่าวไว้แล้วในคำบรรยาย แต่ในส่วนหลังที่ถามว่าจำเลยจะเสียสิทธิในการดำเนินกระบวนการพิจารณาหรือไม่อย่างไร นักศึกษาก็อาจไม่คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ และนึกไม่ออกว่าต้องตอบอย่างไร บางคนคิดไปไกลถึงกับว่าฉันไม่ได้เป็นศาล จะตอบได้อย่างไร ? ความจริงแล้วคำถามลักษณะนี้เป็นคำถามที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปในข้อสอบแทบทุกสถาบัน แท้จริงแล้วก็มีความหมายเพียงว่าถ้าจำเลยไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานในนัดที่สอง (ซึ่งไม่ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา) เช่นนี้จะเกิดผลประการใดกับจำเลยบ้างเท่านั้น ขอให้นักศึกษาพิจารณาจากตรงคำตอบดังต่อไปนี้

ธงคำตอบ

ก.) ป.วิ.พ. มาตรา 200 บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา 198 ทวิ และมาตรา 198 ตริ ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยาน และไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณา

ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันนัดอื่นที่มีใช้วันสืบพยาน ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิการดำเนินกระบวนการพิจารณาของตนในนัดนั้น และทราบกระบวนการพิจารณาที่ศาลได้ดำเนินไปในนัดนั้นด้วยแล้ว

ดังนั้น จึงมีหลักเกณฑ์สำคัญที่จะถือว่าคู่ความขาดนัดพิจารณาได้ 2 ประการคือ

1. คู่ความไม่มาศาลในวันสืบพยานจากมาตรา 1 (10)

คำว่า “วันสืบพยาน” หมายความว่า วันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยาน ฉะนั้น จึงหมายความว่าวันที่มีการสืบพยานในประเด็นพิพาทแห่งคดีกันจริง ๆ ไม่ใช่วันสืบพยานที่เลื่อนไป หรือเป็นวันไต่สวนพยานประกอบคำร้องอื่น

2. และไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี

(คำตอบอยู่ในเอกสารการสอนหน้า 4-14/15)

ข.) กรณีตามอุทธรณ์จากหลักกฎหมายในข้อ ก. จะเห็นว่าการที่คู่ความมาศาลในวันสืบพยานนัดแรก ครบทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่ถือว่าคู่ความฝ่ายใดขาดนัดพิจารณา เพราะวันสืบพยานคือวันที่ศาลทำการสืบพยานนัดแรกเท่านั้น ฉะนั้น ในวันนัดสืบพยานโจทก์ต่อไปเป็นนัดที่ 2 วันนัดนี้ไม่ใช่วันสืบพยานตามความหมายของมาตรา 1(10) ดังกล่าวแล้ว แม้จำเลยจะไม่มาศาลในนัดนี้ก็ไม่ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาแต่อย่างใด

ในคำถามส่วนหลังที่ว่า จำเลยจะเสียสิทธิในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างไรหรือไม่นั้น ก็เป็นการตอบถามตัวบทในมาตรา 200 วรรค 2 ตรง ๆ ว่าถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันนัดอื่นที่มีใช้วันสืบพยาน ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นสละสิทธิการดำเนินกระบวนการพิจารณาของตนในนัดนั้น และทราบกระบวนการพิจารณาที่ศาลได้ดำเนินไปในนัดนั้นด้วยแล้ว (นักศึกษาตอบตามตัวบทมาเพียงเท่านี้ก็จะได้คะแนนแล้ว) แต่ถ้าตอบละเอียดไปถึงกว่านี้ก็จะได้คะแนนมากขึ้นไปอีก คือตอบว่า

1. การที่จำเลยไม่มาศาลเท่ากับสละสิทธิถามค้านพยานโจทก์และคัดค้านพยานเอกสารของโจทก์เฉพาะที่โจทก์นำสืบในนัดนั้นเท่านั้น และ

2. ถือว่าฝ่ายจำเลยที่ไม่มาศาลได้ทราบกระบวนการพิจารณาที่ศาลได้ดำเนินไปในนัดนั้นด้วยแล้ว โดยศาลไม่ต้องแจ้งวันนัดสืบพยานนัดใหม่ให้จำเลยทราบอีก

คงเห็นแล้วว่าข้อสอบของเราไม่ได้ยากจนเกินกำลังสติปัญญาของนักศึกษาเลย ข้อสอบจะอยู่ในเอกสารการสอนแล้วทั้งสิ้น ขอให้นักศึกษาตั้งใจอ่านเอกสารคำสอนให้ดี และเมื่อพบคำถามแนวนี้อีกก็ไม่ต้องตกใจให้ตั้งสติและค่อย ๆ คิดไปตอบไปโดยอธิบายหลักกฎหมายเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยนำข้อเท็จจริงตามข้อสอบมาปรับกับหลักกฎหมายแล้วสรุปตอบต่อไป

ขอให้โชคดีในการสอบทุกครั้งและทุกวิชาครับ



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

อาจารย์ เอกพงศ์ คลังกรณ์

คำถาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 จำเลยให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี จำเลยอุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษ ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรรื้อการลงโทษให้แก่จำเลย แต่เห็นว่าศาลชั้นต้นกำหนดโทษหนักเกินไป จึงพิพากษาแก้โดยกำหนดโทษเสียใหม่ให้จำคุก 1 ปี

ดังนี้ การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษจำเลยเสียใหม่ เป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

มาตรา 185 วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิด แต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้”

มาตรา 192 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พิพากษา หรือสั่ง เกินคำขอ หรือที่มีได้กล่าวในฟ้อง”

มาตรา 215 บัญญัติว่า “นอกจากที่บัญญัติมาแล้ว ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นมา บังคับในชั้นศาลอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลม”

จากบทกฎหมายข้างต้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคสอง หมายความว่า ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องและไม่มีการยกเว้นโทษให้แก่จำเลยตามกฎหมาย ศาลจะต้องพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิด โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคสองนี้ ยังนำไปใช้บังคับในชั้นอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 215 ซึ่งในการพิพากษาลงโทษจำเลยนี้ ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมได้ เช่น ศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยหนักเกินไปศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้ไขให้โทษเบาลงได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคสองและไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ ดังนั้นแม้จำเลยจะอุทธรณ์เพียงขอให้รอกการลงโทษก็ตาม ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าตามพฤติการณ์ยังไม่สมควรรอกการลงโทษจำเลย แต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยหนักเกินไปศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้โทษจำเลยเสียใหม่ให้เหมาะสม โดยศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยจาก 2 ปี เป็น 1 ปี ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคสอง และไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่ขอให้ศาลรอกการลงโทษ ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่งแต่อย่างใด

ดังนั้น ศาลอุทธรณ์จึงพิพากษาแก้กำหนดโทษจำคุกจำเลยเสียใหม่ให้เหมาะสมได้และไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลย

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นสำคัญเพียงประเด็นเดียว คือ การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษจำเลยเสียใหม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยหรือไม่ โดยมีข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก ประเด็นคำถามเรื่อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษจำเลยเสียใหม่ เป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยหรือไม่ นักศึกษาควรยกหลักกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคำถามกล่าวคือ เมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคสอง และห้ามมิให้พิพากษา หรือสั่งเกินคำขอ หรือที่มิได้กล่าวในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง

ประการที่สอง ประเด็นคำถามในเรื่องนี้มีประเด็นย่อยที่ต้องอธิบายและวินิจฉัย คือ เมื่อศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าศาลชั้นต้นกำหนดโทษหนักเกินไป จึงกำหนดโทษเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่รูปคดี อันเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษแก่จำเลยตามความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคสอง ประการต่อมาแม้จำเลยจะอุทธรณ์เพียงขอให้รอกการลงโทษก็ตาม แต่ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจกำหนดโทษเสียใหม่ได้เมื่อโทษที่ศาลอุทธรณ์แก้ไชนั้นเป็นโทษที่เบากว่าที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192

ประการที่สาม นักศึกษาหลายคนไม่สามารถตอบคำถามได้ เนื่องจากจับประเด็นคำถามไม่ได้ ซึ่งประเด็นคำถามสำคัญเรื่องนี้เป็น การพิพากษาคดีนั้นเกินคำขอหรือไม่ แต่มีนักศึกษาหลายคนหลงประเด็นไปตอบเรื่องการอุทธรณ์นั้นต้องห้ามหรือไม่

ประการที่สี่ มีนักศึกษาบางส่วนจับประเด็นปัญหาได้ แต่ไม่สามารถตอบคำถามได้ เพราะไม่ทราบว่า จะนำบทบัญญัติมาตราใดมาตอบ หรือตอบว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โดยกำหนดโทษเสียใหม่ให้จำคุก 1 ปี เป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้อง เพราะจำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษเท่านั้น

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 และมาตรา 192 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิพากษาคดีของศาล อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิพากษาคดีของศาล โดยเฉพาะการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายที่บัญญัติหลักการไว้ค่อนข้างกว้าง จึงจำเป็นต้องอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่อดูแนวการตีความ หรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลาว่างในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยาย สอนเสริม เพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยาย สอนเสริมได้



กฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ทัศนศิลป์กุล

คำถาม

ข้อ 1 บริษัทเรโนลต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและมีภูมิลำเนาที่ประเทศฝรั่งเศส ต่อมาบริษัทเรโนลต์เห็นว่าอาเซียนได้จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีการเปิดเสรีการลงทุน จึงตัดสินใจมาตั้งบริษัทในอาเซียนโดยจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 2555 และกฎหมายการลงทุนของประเทศสิงคโปร์ไม่ได้จำกัดสัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวจะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าคนชาติ บริษัทเรโนลต์จึงจดทะเบียนตั้งบริษัทชื่อบริษัทเรโนลต์ สิงคโปร์ จำกัด และถือหุ้นโดยคนชาติฝรั่งเศสทั้ง 100% ต่อมาบริษัทเรโนลต์ จำกัดประสงค์จะมาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยเพื่อประกอบกิจการทำการเกษตร ปลูกผักผลไม้เพื่อส่งออกไปยังตลาดประชาคมยุโรป บริษัทเรโนลต์ สิงคโปร์ จึงเข้ามาจดทะเบียนในไทยชื่อบริษัทเรโนลต์เกษตรไทย จำกัด ในปีเดียวกัน และถือหุ้นโดยบริษัท เรโนลต์สิงคโปร์ 30% ถือหุ้นโดยบริษัทเรโนลต์ จำกัด 20% และถือหุ้นโดยบริษัทเกษตรไทย จำกัด อีก 50% ปราบกฏว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่อนุญาตให้จดทะเบียนบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำการเกษตร เพราะเป็นภาคส่วนที่ไทยไม่เปิดการลงทุนตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว เพราะบริษัทเรโนลต์เกษตรไทย จำกัด ถือหุ้นโดยคนต่างด้าว 50% และการเกษตรเป็นการลงทุนที่ไม่เปิดให้คนต่างด้าวลงทุน บริษัทเรโนลต์เกษตรไทย จำกัด จึงฟ้องร้องกระทรวงพาณิชย์ว่าบริษัทไม่ได้รับความเป็นธรรม และไทยไม่ปฏิบัติตามความตกลงอาเซียนที่เปิดเสรีภาคการเกษตรและเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสให้การคุ้มครองตามหลักกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนชาติทางการทูต และให้รัฐบาลไทยรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐ หากนักศึกษาเป็นทีปรีษาทางกฎหมายไทย ท่านจะให้คำแนะนำอย่างไร

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

พันธกิจภายใต้อาเซียน

45 ปีของการก่อตั้งอาเซียน มุ่งเน้นในการพิจารณาพัฒนาความตกลงที่สำคัญที่มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของระบบเศรษฐกิจ เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) ซึ่งเกิดจากการผนวกความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน (Agreement on the ASEAN Investment Area : AIA) ผนวกกับความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนอาเซียน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment) ความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation) ความตกลง

ว่าด้วยอัตราภาษีศุลกากรร่วม (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff : CEPT) ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) เป็นต้น

ส่วนการเปิดเสรีทางการลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) การเกษตร ป่าไม้ เหมืองแร่ การประมง และการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต เกษตร ป่าไม้ เหมืองแร่ การประมงด้วย

การเปิดเสรีอาเซียนเป็นการเปิดเสรีแบบเปิด (Open Regionalism) ที่สามารถให้สิทธิประโยชน์แม้กับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก บุคคลที่จะลงทุนในอาเซียนและสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากการรวมตัวและการร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียน นิติบุคคลที่มีสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียน และ นิติบุคคลใดๆที่เข้ามาลงทุนตั้งกิจการที่สำคัญในอาเซียน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า อาเซียนเปิดกว้างกว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคใดๆที่เคยมีมาก่อน อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีและจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลบังคับในปี 2558 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถที่จะตั้งข้อสงวนไม่เปิดภาคส่วนที่ตนสงวนไว้ในรายการ Negative List หรือ Sensitive List หากได้ยื่นรายการข้อสงวนนี้ไว้ต่อ AIA Council ซึ่งประเทศไทยได้ยื่นรายการสงวนชั่วคราวไว้ดังนี้

TEMPORARY EXCLUSION LIST
FOR THE OPENING UP OF INDUSTRIES FOR THE
MANUFACTURING, AGRICULTURE, FISHERY, FORESTRY,
MINING & QUARRYING SECTORS

Thailand

SECTOR	ISIC	SUBMISSIONS	
		SECTOR/INDUSTRIES	RESTRICTION/ REQUIREMENTS
Industries Closed to Both National and Foreign Investors			
Manufacturing, Agriculture, Fishery, Forestry, Mining & Quarrying		NIL	NIL
Industries Closed Only to Foreign Investors			
Manufacturing, Agriculture, Fishery, Forestry, Mining & Quarrying		NIL	NIL
Industries Open with Restriction to Foreign Investors			
Agriculture (for ASEAN Investors)	0111	Artificially propagated or plant breeding	- Foreign equity participation is restricted to less than 50% of registered capital - Foreign equity participation of 50% or more of registered capital can be made, subject to following
Fishery	0500	Fishery, specifically marine animal culture	

Forestry	0200	Logging from plantation	conditions; 1. Shall obtain permission from Director-General of Department of Business Development ¹ , with approval of Foreign Business Committee
----------	------	-------------------------	--

Note: The current Lists are subject to further review.

SECTOR	ISIC	SUBMISSIONS	
		SECTOR/INDUSTRIES	RESTRICTION/ REQUIREMENTS
			2. Shall receive promotion under Investment Promotion Law, or shall obtain permission under law governing Industrial Estate Authority of Thailand or other related laws • Shall have minimum capital invested at commencement of a business not less than that prescribed by Ministry of Commerce’s regulations, which in any case not less than 3 million baht • Shall apply for license or certificate from Department of Business Development • Shall comply with other conditions prescribed in Foreign prescribed in Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) and other related laws

Note: The current Lists are subject to further review

SENSITIVE LIST
FOR THE OPENING UP OF INDUSTRIES FOR THE
MANUFACTURING, AGRICULTURE, FISHERY, FORESTRY,
MINING & QUARRYING SECTORS

Thailand

SECTOR	ISIC	SUBMISSIONS	
		SECTOR/INDUSTRIES	RESTRICTION/ REQUIREMENTS
Industries Closed to Both National and Foreign Investors			
Manufacturing	1542	Manufacture of sugar from sugarcane	Subject to Cabinet's decision
Industries Closed Only to Foreign Investors			

¹ These lists shall be reviewed at least once every one year. The name of Department of Commercial Registration has been changed to the “Department of Business Development” due to the organization restructuring of the Ministry of Commerce

Manufacturing, Agriculture, Fishery, Forestry, Mining & Quarrying		NIL	NIL
Industries Open with Restriction to Foreign Investors			
Manufacturing	2029	Manufacture of carved wood	- Foreign equity participation is restricted to less than 50% of registered capital - Foreign equity participation of 50% or more of registered capital can be made, subject to following conditions; - Shall obtain permission from Minister of Commerce, with approval of Cabinet, and shall also fulfill following requirements:
	0122 2221	Manufacture of Thai silk threads, Thai silk weaving or Thai silk pattern printing	
	3692	Manufacture of Thai musical instruments	
	2720	Manufacture of gold ware, silverware, nielloware, bronzeware or lacquerware	
	2693	Manufacture of crockery of Thai arts and culture	
	2021 2023 2029	Wood fabrication for production of furniture and utensils	

Note: The current Lists are subject to further review

SECTOR	ISIC	SUBMISSIONS	
		SECTOR/INDUSTRIES	RESTRICTION/ REQUIREMENTS
			- Shall have Thai nationals, or juristic persons that are not foreigners under this Act, shall hold not less than 40% of registered capital. However, Minister of Commerce with approval of Cabinet may reduce said requirement to not less than 25%. - Shall have Thai nationals held at least two-fifths of total directors - Shall receive promotion under Investment Promotion Law, or shall obtain permission under law governing Industrial Estate Authority of Thailand or other related laws - Shall have minimum capital invested at commencement of a business not less than that prescribed by Ministry of Commerce's regulations, which in any case not less than 3 million baht - Shall apply for license or certificate from Department of Business Development - Shall comply with other conditions prescribed in Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) and other related laws

Note: The current Lists are subject to further review

SECTOR	ISIC	SUBMISSIONS	
		SECTOR/INDUSTRIES	RESTRICTION/ REQUIREMENTS
	1531	Rice milling	- Foreign equity participation is restricted to less than 50% of registered capital - Foreign equity participation of 50% or more of registered capital can be made, subject to following conditions; - Shall obtain permission from Director-General of Department of Commercial Registration, with approval of Foreign Business Committee - Shall receive promotion under Investment Promotion Law, or Shall obtain permission under law governing Industrial Estate Authority of Thailand or other related laws - Shall have minimum capital invested at commencement of a business not less than that prescribed by Ministry of Commerce's regulations, which in any case not less than 3 million baht - Shall apply for license or certificate from Department of Business Development. - Shall comply with other conditions prescribed in Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) and other related laws
	2029 2021	Manufacture of plywood, veneer board, chipboard or hardboard	
	2694	Manufacture of lime	

Note: The current Lists are subject to further review.

SECTOR	ISIC	SUBMISSIONS	
		SECTOR/INDUSTRIES	RESTRICTION/ REQUIREMENTS
	3694	Manufacture of playing cards	Shall obtain permission from Director-General of Excise Department according to Tobacco Act B.E. 2509 (1966) or Playing Cards Act B.E. 2486 (1943)
	1600	Manufacture of cigarette	
Agriculture	1422	Salt farming, including efflorescent salt production	- Foreign equity participation is restricted to less than 50% of registered capital - Foreign equity participation of 50% or more of registered capital can be made, subject to following conditions; - Shall obtain permission from Minister of Commerce, with approval of cabinet, and shall also fulfill following requirement: - Shall have Thai nationals, or juristic persons that are not foreigners under this Act, held not less than 40% of registered capital. However, Minister of Commerce with approval of Cabinet may reduce said requirement to not less than 25% - Shall have Thai nationals held at least two-fifths of total directors or - Shall receive promotion under Investment Promotion Law, or must obtain permission under law governing Industrial Estate Authority of Thailand or other related laws
	0122, 2221	Silkworm farming	
Mining & Quarrying		Mining including rock blasting or crunching	
		Rock salt mining	

Note: The current Lists are subject to further review.

SECTOR	ISIC	SUBMISSIONS	
		SECTOR/INDUSTRIES	RESTRICTION/ REQUIREMENTS
			• Shall have minimum capital invested at commencement of a business not less than that prescribed by Ministry of Commerce's regulations, which in any case not less than 3 million baht • Shall apply for license or certificate from the Department of Business Development • Shall comply with other conditions prescribed in Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) and other related laws
Agriculture (of Non-ASEAN Investors)	0111	Artificially propagated or plant breeding	• Foreign equity participation is restricted to less than 50% of registered capital • Foreign equity participation of 50% or more of registered capital can be made, subject to following conditions; - Shall obtain permission from Director-General of Department of Commercial Registration, with approval of Foreign Business Committee - Shall receive promotion under Investment Promotion Law, or Shall obtain permission under law governing Industrial Estate Authority of Thailand or other related laws

Note: The current Lists are subject to further review.

SECTOR	ISIC	SUBMISSIONS	
		SECTOR/INDUSTRIES	RESTRICTION/ REQUIREMENTS
			• Shall have minimum capital invested at commencement of a business not less than that prescribed by Ministry of Commerce's regulations, which in any case not less than 3 million baht • Shall apply for license or certificate from Department of Business Development. • Shall comply with other conditions prescribed in Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) and other related laws

Note: The current Lists are subject to further review.

SENSITIVE LIST
FOR THE GRANTING OF NATIONAL TREATMENT FOR THE
MANUFACTURING, AGRICULTURE, FISHERY, FORESTRY,
MINING & QUARRYING SECTORS

Thailand

SUBMISSIONS	
MEASURES	DESCRIPTION OF TREATMENT
Manufacturing, Agriculture, Fishery, Forestry, Mining & Quarrying	
Foreign Equity Participation	- Foreign equity participation is restricted to less than 50% of registered capital - Foreign equity participation of 50% or more of registered capital can be made, subject to following conditions: - All activities listed in SL shall obtain permission from Minister of Commerce, with approval of Cabinet, or Director General of the Department of Business Development, with approval of Foreign Business Committee, as case maybe - Shall receive promotion under Investment Promotion Law, or shall obtain permission under law governing Industrial Estate Authority of Thailand or other related laws.
Capital Requirements	- In case of industries which are open with restriction to foreign investor under TEL and SL, minimum capital invested at commencement of a business shall not be less than that prescribed in the Ministry of Commerce's regulations, which in any case shall not be less than two million Baht. - In case of industries which are open without restriction to foreign investor under SL, minimum capital invested at commencement of a business shall not be less than that prescribed in the Ministry of Commerce's regulations, which in any case shall not be less than two million Baht.
License or Certificate Requirements	Only business under TEL and SL shall apply for license or certificate from Department of Business Development.

Note: The current Lists are subject to further review

SUBMISSIONS	
MEASURES	DESCRIPTION OF TREATMENT
Manufacturing, Agriculture, Fishery, Forestry, Mining & Quarrying	
Land Ownership	- Foreign investors are permitted to own land according to Investment Promotion Act B.E. 2520: Industrial Estate Authority of Thailand Act B.E. 2522 (1979), and the Petroleum Act. B.E. 2514 (Article 65 on oil concessionaire). - The Amended Land Code (No.8) B.E. 2542 (1999) allows foreigners with registered capital of at least 40 million baths, to own land for residential purpose not exceeding 1 rai. Also, they must obtain Ministerial permission.
Residence Ownership	- Foreigners are not allowed to own housing except condominium. - The total condominium units owned by foreigners must not exceed 49% of the condominium units in each condominium unless the condominium is located in Bangkok or other governmental vicinities specified by the Ministerial regulations. The total area of land must not exceed 5 rai.
Measures related services (Government Procurement)	Subject to the regulations of the Office of the Prime Minister.
Employment of Foreign Personal	The Working Aliens Act. B.E. 2522 provides list of 39 vocations that are prohibited to foreign investors. It has been under negotiation of the Service Working Group.
Other Conditions	Foreign business shall comply with other conditions prescribed in Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) and other related laws.

Note: The current Lists are subject to further review

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“คนต่างด้าว” หมายความว่า

(๑) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

(๒) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

(๓) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) นิติบุคคล ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น

(ข) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (๑)

(๔) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น

บัญชีหนึ่งของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษ

- (๑) การทำกิจการหนังสือพิมพ์ การทำกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์
- (๒) การทำนา ทำไร่ หรือทำสวน
- (๓) การเลี้ยงสัตว์
- (๔) การทำป่าไม้และการแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ
- (๕) การทำการประมงเฉพาะการจับสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยและในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศ

ไทย

- (๖) การสกัดสมุนไพรไทย
- (๗) การค้าและการขายทอดตลาดโบราณวัตถุของไทยหรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
- (๘) การทำหรือหล่อพระพุทธรูป และการทำบาตร
- (๙) การค้าที่ดิน

วินิจฉัย

การที่บริษัทเรโนลต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและมีภูมิลำเนาที่ประเทศฝรั่งเศส ได้เข้ามาตั้งบริษัทในอาเซียนโดยจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 2555 และกฎหมายการลงทุนของประเทศสิงคโปร์ไม่ได้จำกัดสัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวว่าจะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าคนชาติ บริษัทเรโนลต์จึงจดทะเบียนตั้งบริษัทชื่อบริษัทเรโนลต์ สิงคโปร์ จำกัด และถือหุ้นโดยคนชาติฝรั่งเศสทั้ง 100% และต่อมาบริษัทเรโนลต์ จำกัด บริษัทเรโนลต์ สิงคโปร์ ได้เข้ามาจดทะเบียนในไทยชื่อบริษัทเรโนลต์เกษตรไทย จำกัด ในปีเดียวกัน และถือหุ้นโดยบริษัท เรโนลต์สิงคโปร์ 30% ถือหุ้นโดยบริษัทเรโนลต์ จำกัด 20% และถือหุ้นโดยบริษัทเกษตรไทย จำกัด อีก 50% โดยประสงค์จะมาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยเพื่อประกอบกิจการทำการเกษตร ปลูกผักผลไม้เพื่อส่งออกไปยังตลาดประชาคมยุโรป จึงพิจารณาได้ว่าบริษัทเรโนลต์เกษตรไทย จำกัด เป็นบริษัทต่างด้าวเนื่องจากถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวเกินกว่า 49% ซึ่งบริษัทต่างด้าวไม่สามารถประกอบธุรกิจการทำเกษตร และถือครองที่ดินได้ในขณะที่เข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยในปี 2555 และในปี 2555 ยังไม่ถึงกำหนดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย และเป็นอำนาจอธิปไตยของรัฐในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบุคคลต่างด้าวในประเทศนั้นๆ ดังนั้นการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายจึงไม่เป็นการกระทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ กระทำการก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนต่างด้าวในการที่ประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบ เนื่องจากนิติบุคคลต่างด้าวยังไม่มีสิทธิตามพันธกิจอาเซียนในขณะนั้น

ธงคำตอบ

บริษัทเรโนลต์เกษตรไทยจำกัด จึงไม่ได้รับความเสียหายในอันที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสให้ความคุ้มครองคนชาติทางการทูตได้เพราะไม่ถือว่าเสียหายอีกทั้งการจะใช้สิทธิดังกล่าวคนต่างด้าวจะต้องไม่ได้กระทำการที่ผิดกฎหมายด้วย จากการปฏิบัติตามกฎหมายไทย และ ประเทศไทยก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายไทยในการบังคับใช้กฎหมายภายในของไทยโดยชอบ

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว การจัดตั้งองค์กรธุรกิจโดยคนต่างด้าวในประเทศไทย การสงวนภาคส่วนธุรกิจที่ไม่เปิดเสรีสำหรับคนต่างด้าว และพันธกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการเปิดเสรีการลงทุน การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบังคับใช้ความตกลงจัดตั้งเขตการลงทุนเสรีอาเซียน

นักศึกษาที่ทำข้อสอบข้อนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่เนื่องจากไม่เข้าใจประเด็นพันธกิจในการเปิดเสรีเขตการลงทุนอาเซียนว่าประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามความตกลง เมื่อไหร่ อย่างไร ทั้งนี้ตามความตกลง ACIA ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อความตกลงดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับ คือ ในปี พ.ศ.2558 และรัฐสมาชิกอาเซียนยังสามารถตั้งข้อสงวนได้ ตามความตกลง ซึ่งประเทศไทยยังสามารถบังคับการตามกฎหมายภายในได้ตราบท่าที่ความตกลงฉบับนี้ยังไม่มีผลบังคับให้อาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจ แต่เมื่อสนธิสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2558 แล้ว ประเทศไทยก็ต้องบังคับการให้เป็นไปตามพันธกิจที่ประเทศไทยผูกพันอยู่ เว้นแต่ประเทศไทยจะได้ยื่นรายการสงวนในภาคส่วน หรืออนุภาคส่วนที่ไทยยังไม่เปิดเสรี ซึ่งสามารถมีการพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได้

การศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศนั้น นักศึกษานอกจากต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาวิชาแล้วยังต้องมีความรอบรู้ รอบตัว รอบด้านในวิทยาการ และพัฒนาการที่ก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจะสามารถเข้าใจ ทันสมัย และทันต่อพัฒนาการของโลกได้

ข้อ 2 นายลีซู และนางรายอ ชาวพม่า ซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 และมีบุตรชายที่เกิดในประเทศไทยในปี 2536 ชื่อนายลียอ ต่อมาในปี 2555 นายลียอ ลักลอบได้เสียกับนางยูโซะ ซึ่งเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจนนางยูโซะตั้งครรภ์และกลับไปคลอดบุตรที่ประเทศมาเลเซีย ชื่อเด็กชายลีโซะ ซึ่งต่อมานางยูโซะได้บอกความจริงแก่บุตรชายว่าบิดาชื่อนายลียอ อยู่ในประเทศไทย ลีโซะและยูโซะจึงกลับมาติดตามนายลียอเพื่ออยู่กับนายลียอซึ่งเป็นบิดาโดยพฤตินัยของลีโซะ เมื่อยูโซะและลีโซะเข้ามาในประเทศไทยแล้วอยู่ในประเทศไทยได้เพียง 3 เดือน ก็ถูกตำรวจไทยจับและส่งออกนอกประเทศ ลีโซะและยูโซะต่อสู้ว่าบุตรชายคือ ลีโซะเป็นคนไทย เพราะบิดาเป็นคนไทยโดยสามารถพิสูจน์ DNA ได้ หากความจริงเป็นเช่นนั้นคือลีโซะเป็นบุตรสืบสายโลหิตของลียอจริง ดังนั้น ลีโซะจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบายพร้อมทั้งยกหลักกฎหมายประกอบการวินิจฉัย

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508, แก้ไข พ.ศ.2535, และ แก้ไข พ.ศ.2551

มาตรา 7 บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

- (1) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
- (2) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง

มาตรา 7 ทวิ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ย่อมไม่ได้รับสัญชาติไทย ถ้าในขณะที่เกิดบิดาตามกฎหมาย หรือบิดาซึ่งมิได้มีการสมรสกับมารดาหรือมารดาของผู้นั้นเป็น

- (1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
- (2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราวหรือ
- (3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

มาตรา 23 บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ข้อ 1 และผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ข้อ 2 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

ถ้าบุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเป็นผู้มีคุณสมบัติดีหรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย ให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีคำสั่งอันมีผลให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งยื่นคำขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาในปัจจุบัน

วินิจฉัย

นายสีชู และนางรายอ ชาวพม่า เป็นผู้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 โดยได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ และมีบุตรชายที่เกิดในประเทศไทยในปี 2536 ชื่อนายสียอ ซึ่งเกิดมาในขณะที่พระราชบัญญัติสัญชาติ ปี พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติมาตรา 7 ทวิ มาบังคับใช้แล้วยกเว้นบุคคลที่เกิดในประเทศไทยที่จะได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนไม่ให้ได้สัญชาติไทย โดยหลักเกณฑ์ตามกฎหมายในมาตรา 7 ทวิ นายสียอ จึงเป็นบุตรของบุคคลที่เข้าคุณสมบัติตามมาตรา 7 ทวิ ที่จะไม่ได้รับสัญชาติไทยดังนั้นต่อมา

ในปี 2555 นายลियो ลักลอบได้เสียกับนางยูโซะ ซึ่งเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจนนางยูโซะตั้งครรภ์และกลับไปคลอดบุตรที่ประเทศมาเลเซีย ชื่อเด็กชายลีโซะ

ในกรณีนี้ ลีโซะจึงเกิดมาโดยมีบิดา มารดา เป็นต่างด้าวทั้งคู่ และมีมารดาที่เป็นบุคคลที่เข้าเมืองมาชั่วคราวเป็นนักท่องเที่ยว ดังนั้น ลีโซะ จึงเข้าข้อยกเว้นในการไม่ได้สัญชาติตาม มาตรา 7 ทวิ เช่นกัน เมื่อลियोไม่ได้สัญชาติไทยจึงไม่อาจถือเอาประโยชน์จากการพิสูจน์ DNA ว่าเป็นบุตรของลियो

เมื่อยูโซะและลีโซะเข้ามาในประเทศไทยแล้วอยู่ในประเทศไทยได้เพียง 3 เดือน ก็ถูกตำรวจไทยจับและส่งออกนอกประเทศ ข้อต่อสู้ของลีโซะและยูโซะที่ต่อสู้ว่า ลีโซะเป็นคนไทย เพราะบิดาเป็นคนไทยโดยสามารถพิสูจน์ DNA ได้ จึงฟังไม่ขึ้น

อย่างไรก็ตาม มาตรา 23 ของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้บุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ ให้ได้สัญชาติไทยได้ถ้าบุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเป็นผู้มีความประพฤติดีหรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย ให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับดังนั้น หากลियो สามารถพิสูจน์ว่าเกิดและอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และ เป็นผู้มีความประพฤติดี ดังกล่าวก็ให้ได้สัญชาติไทยโดยยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทยในเอกสารการทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาในปัจจุบันในกรณีนี้ เมื่อลियोได้สัญชาติไทย ลีโซะก็จะได้ประโยชน์ในข้อนี้ไปด้วย หากลियोได้สัญชาติไทยตั้งต่อก่อนลีโซะเกิด ลีโซะก็จะได้สัญชาติไทยได้โดยพิสูจน์ DNA ว่าเป็นบุตรของลियो ที่ได้สัญชาติไทยต่อไป กรณีนี้ ลีโซะก็จะถูกเนรเทศออกนอกประเทศไม่ได้ เพราะจะเนรเทศคนชาติออกนอกประเทศไม่ได้

ชงคำตอบ

หากลियोได้ประโยชน์จากมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติสัญชาติ 2551 ในการได้สัญชาติไทยก่อนลีโซะเกิด ลีโซะก็จะได้สัญชาติไทยในฐานะที่มีบิดาเป็นคนสัญชาติไทยได้ หากลियोไม่ได้ยื่นขอลงรายการสัญชาติไทยต่อนายทะเบียนตามมาตรา 23 ลियोก็จะไม่ได้สัญชาติไทยและ ลีโซะก็จะไม่ได้สัญชาติไทยด้วย

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน ความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา เกี่ยวกับการได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ ทั้งหลักเกณฑ์ ข้อยกเว้น และ การได้สัญชาติไทยตามกฎหมายใหม่ที่ตราบัญญัติขึ้นในปี พ.ศ.2551 เกี่ยวกับการให้สิทธิคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทย แต่ไม่ได้สัญชาติไทยให้ได้สัญชาติไทยเพื่อหลักมนุษยธรรม และ สิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามกฎหมายใหม่ในมาตรานี้ยังมีข้อบกพร่องในการบัญญัติกฎหมาย ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติได้

นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบได้ไม่ครบถ้วน ถึงมาตรา 23 ในพระราชบัญญัติสัญชาติไทยที่แก้ไขใหม่ปี พ.ศ.2551 ส่วนใหญ่จะตอบได้เพียงมาตรา 7(2) และ มาตรา 7 ทวิ หรือ ตอบมาตรา 7(1) วรรคสอง เท่านั้น ไม่ได้ตอบไปถึงมาตรา 23 ดังกล่าว ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องศึกษาให้ครอบคลุมครบถ้วนจึงจะสามารถวิเคราะห์กฎหมายได้อย่างถูกต้องและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ถูกต้อง อีกทั้งสามารถวิเคราะห์กฎหมายในทางปฏิบัติได้

ข้อ 3 หากกองทหารของกัมพูชาถูกรานอาณาเขตประเทศไทย และเข้ามาจุดคว่ำฆ่าชนพื้นเมืองไทย ทั้งหมู่บ้าน และปล้นสดมภ์อาหารของชาวบ้านชาวไทย รัฐบาลไทยได้แจ้งให้หยุดการกระทำดังกล่าว แต่กองทหาร กัมพูชา ก็เพิกเฉยกลับรุกรานชายแดนไทยเข้ามาเรื่อย ๆ ดังนี้ รัฐบาลไทยจะสามารถนำคดีฟ้องร้องนายพลและ กองทหารกัมพูชาต่อศาลอาญาระหว่างประเทศได้หรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบายพร้อมทั้งยกหลักกฎหมาย ประกอบการวินิจฉัยด้วย

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ศาลอาญาระหว่างประเทศมีการดำเนินงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐภาคีสมาชิก รัฐที่ยอมรับ เขตอำนาจของศาล และสหประชาชาติมีบทบาทในการเสนอคดีอาญาระหว่างประเทศต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ ด้วย

ศาลอาญาระหว่างประเทศมีเขตอำนาจเหนือรัฐที่เป็นภาคีสมาชิก และประเทศที่ยอมรับเขตอำนาจ ของศาล และมีอำนาจพิจารณาเหนือคดีอาญาที่ร้ายแรงได้แก่ อาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรมสงคราม และ การรุกราน ศาลอาญาระหว่างประเทศจะลงโทษผู้กระทำผิดที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์

สหประชาชาติมีอำนาจในการเสนอคดีต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ ตามกลไกในการรักษาสันติภาพ ของโลก ในหมวด 7 แห่ง กฎบัตรสหประชาชาติ และศาลอาญาระหว่างประเทศมีการดำเนินงานที่ต้องอาศัย ความร่วมมือของรัฐภาคี และรัฐที่ยอมรับเขตอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัญหาในทางปฏิบัติ หลายประการทำให้การดำเนินงานของศาลอาญาระหว่างประเทศมีอุปสรรค ได้แก่การไม่ยอมรับของประเทศ มหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย และกลุ่มประเทศที่ก่อภัยร้ายแรงต่อมนุษยชาติ เช่นอิรัก และกลุ่ม ประเทศอาหรับ ซึ่งประเทศเหล่านี้ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับอาชญากรรมระหว่างประเทศ

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ สถานะของศาลอาญาระหว่างประเทศ กับประเทศไทยนั้น เป็นประเด็น ที่สำคัญทีเดียวเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมในการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ และการประชุมคณะทูต แห่งสหประชาชาติ และได้ร่วมรับรองธรรมนูญกรุงโรม แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน ธรรมนูญกรุงโรม

ศาลอาญาระหว่างประเทศมีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีอาญาที่ร้ายแรง 4 ประเภท คือ อาชญากรรม ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรมสงคราม และ อาชญากรรมการรุกราน

และศาลอาญาระหว่างประเทศมีอำนาจในการพิจารณาคดีบุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ประมุข หรือผู้นำของรัฐ ผู้นำรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ บุคคลที่เป็นตัวแทนของรัฐไม่ว่าตำแหน่งใดๆ ไม่อาจรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศได้ หากได้กระทำความผิดดังกล่าว นายพล ผู้บังคับบัญชา ผู้ควบคุม กำกับ หรือผู้บัญชาการรบ ก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ทารุณโหดร้าย และอาจถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีหากได้กระทำการอันเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติดังกล่าว อันเป็นผล จากการบังคับบัญชา หรือการบัญชาการ ควบคุม กำกับ การ ของบุคคลเหล่านี้

ความสัมพันธ์กับศาลภายในและศาลอาญาระหว่างประเทศ ศาลอาญาระหว่างประเทศไม่ได้เข้ามาแทนที่ศาลภายใน แต่จะทำหน้าที่เสริมเขตอำนาจศาลภายใน ศาลอาญาระหว่างประเทศจะเข้ามาสำรวจ ตรวจสอบ สอบสวน ใต้สวน และดำเนินคดีอาญาที่ร้ายแรงนั้น ต่อเมื่อรัฐ หรือศาลภายในไม่สามารถที่จะดำเนินคดี หรือไม่เต็มใจ ตั้งใจ ที่จะดำเนินคดีอย่างแท้จริง ซึ่งในกรณีนี้จะพิจารณาโดยผู้พิพากษาของศาล หรือมีการดำเนินคดีที่ล่าช้าเกินความจำเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการดำเนินคดีในลักษณะที่กระทำขึ้นเพียงเพื่อที่จะคุ้มครองปกป้องผู้กระทำความผิดให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษนั้น ไม่ทำให้ไม่สามารถนำคดีดังกล่าวเสนอต่อศาลอาญาระหว่างประเทศได้

วินิจฉัย

การที่กองทหารของกัมพูชา รุกรานอาณาเขตประเทศไทย และเข้ามามุ่ดคร่ำข่มขืนหญิงไทยทั้งหมู่บ้าน และปล้นสดมภ์อาหารของชาวบ้านชาวไทย โดยรัฐบาลไทยได้แจ้งให้หยุดการกระทำดังกล่าว แต่กองทหารกัมพูชา ก็เพิกเฉยกลับรุกรานชายแดนไทยเข้ามาเรื่อย ๆ เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และมีความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ในการมุด คร่ำ ข่มขืนหญิงไทยทั้งหมู่บ้าน และ รุกรานอาณาจักไทย

แม้ประเทศไทยจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศแต่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ทั้งไทยและกัมพูชา จึงสามารถใช้กลไกผ่านสหประชาชาติในเรื่องการนำข้อพิพาทเสนอต่อศาลอาญาระหว่างประเทศโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้และสามารถดำเนินคดีต่อทั้งนายพลและนายทหารกัมพูชาที่กระทำการได้

ธงคำตอบ

แม้ไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศในขณะนี้ แต่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ จึงสามารถเรียกร้องผ่านกลไกของสหประชาชาติให้นำคดีสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศได้ เว้นแต่ศาลภายในของกัมพูชาได้ดำเนินคดีต่อศาลภายในเสียก่อน อย่างมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นอำนาจศาลก็จะกลับคืนสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศได้อีก หากการพิจารณาคดีของศาลภายในล้มเหลวและไม่จริงจัง ในการดำเนินคดี หรือ ถูกแทรกแซง

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา เกี่ยวกับเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องเขตอำนาจศาล และการตีความฐานความผิดที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาล นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ตอบไม่ได้เพราะไม่เข้าใจสภาพการกระทำความผิดว่า การกระทำใดเป็นการกระทำความผิดที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ ข้อสอบในข้อนี้ไม่ยาก แต่นักศึกษาต้องหมั่นศึกษาและคิด วิเคราะห์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลดังกล่าวให้เข้าใจชัดเจนก็จะสามารถทำข้อสอบข้อนี้ได้โดยไม่ยากนัก
